

1500578-37.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... o local é conhecido como ponto de tráfico e os réus são conhecidos pela prática de tráfico, inclusive já conduziu Diogo à Delegacia, com drogas, mas ele foi autuado como usuário. Já tinha abordado Herik na região do bar do Pantera. Herik tinha dinheiro. Com Diogo, nada foi encontrado. Perto de onde Herik estava a droga, na mureta. Havia 19 porções de crack. Os réus alegaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500578-37.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500578-37.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2107832/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 11214353 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

1503/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2107832 - 06º D.P. PIRACICABA,

1503/20/922 - 06º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO OLIVEIRA MAIELLI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Processo nº 1500578-37

VISTOS.

DIOGO OLIVEIRA MAIELLI e HERIK AUGUSTO FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29, do Código Penal, porque no dia 03 de maio de 2020, às 08h40, nas proximidades do denominado "Bar do Pantera", sito à rua Pedro Ferraz Pacheco, nº 50, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, mantinham em depósito, para mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, 19 (dezenove) "pedras de crack", substância

entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de constatação preliminar a fls. 17/19).

Segundo a denúncia, guardas municipais passavam pelo sobredito endereço, conhecido como “ponto de tráfico de drogas”, quando avistaram e suspeitaram da atitude dos réus que “aparentemente trocavam algo entre si”. Os réus já eram conhecidos como autores de mercancia ilícita de drogas, o que motivou abordagem de praxe. Assim que se aproximaram, o réu Diogo “tentou sair do local de forma disfarçada”, enquanto Herik continuou sentado.

Em revista pessoal, na posse de Herik foi apreendida a quantia de R\$ 51,55 (cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), em espécie (auto de exibição e apreensão a fls. 14/15) e próximo ao lugar em que ele estava sentado, foi apreendida uma sacola com 19 “pedras de crack” (auto de exibição e apreensão a fls. 14/15).

Os guardas conheciam os réus e o denominado “Bar do Pantera” é conhecido “ponto de tráfico de drogas” na cidade. Se fossem meros usuários, os réus não ficariam no local com a droga individualizada em porções para comercialização, pois sabem dos riscos de permanecerem no local de alta incidência de policiamento.

Diante das circunstâncias da prisão, apreensão da droga em porções individualizadas para venda e dinheiro em espécie proveniente do tráfico ilícito, infere-se que o estupefaciente destinava-se à mercancia ilícita ou a consumo de terceiras pessoas. A denúncia foi oferecida (fls. 148), sendo determinada a notificação dos réus para oferecerem defesa prévia, nos termos do artigo 55, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06 (fls. 149/150).

Os réus foram notificados (fls. 165 e 170) e apresentaram resposta escrita. O réu Herik solicitou a realização de exame de dependência toxicológica, liberdade provisória, bem como alegou enquadramento equivocado (fls. 157/163). O réu Diogo alegou que não há questões preliminares conhecidas e as questões de mérito serão tratadas posteriormente, requerendo também a revogação da prisão preventiva (fls. 183/188).

A denúncia foi recebida (fls. 206/208). Posteriormente, verificada a possibilidade de realização de audiência virtual, foi designada audiência (fls. 311/312). Os réus foram citados (fls. 356 e 358).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, duas testemunhas de defesa, sendo os réus foram interrogados (link de acesso a fls. 346). O julgamento foi convertido em diligências, a fim de que fosse realizado incidente de dependência toxicológica dos réus, a pedido do Ministério Público (fls. 343/346).

A pedido da Defesa, a instauração do exame de dependência do corréu Diego foi desconsiderado, concedendo-se aos réus a liberdade provisória (fls. 378/379). Juntadas as perícias, encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia, sem aplicação do privilégio, diante da reincidência (fls. 426/434).

A Defensoria Pública, em defesa dos réus, preliminarmente, pleiteou o reconhecimento da ilicitude probatória em razão da atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal, com a consequente absolvição dos réus. No mérito, requereu a desclassificação do delito imputado para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não restou comprovada que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização. Caso seja efetuada a desclassificação do delito, necessária a absolvição dos réus tendo em vista a inconstitucionalidade do referido tipo. Subsidiariamente, no caso de condenação nos termos da denúncia, pleiteia fixação da pena-base no mínimo legal; aumento de 1/6 pela reincidência; fixação de regime prisional menos gravoso; reconhecimento da detração; direito de apelar em liberdade (fls. 441/453 e 475/486).

É o relatório.

DECIDO.

I) Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante dos réus, porque os guardas municipais apenas abordaram os réus, contra quem já havia denúncia de tráfico de drogas, próximos a bar que é ponto de comércio ilícito de estupefaciente e, localizadas as drogas, eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

Anote-se que, em que pese à supracitada legislação seja objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 5156, em trâmite perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, é certo que o Ministro Gilmar Mendes já proferiu decisão, na qual indeferiu a ação, de forma que, mesmo sem o trânsito em julgado, a lei em questão continua em pleno vigor no ordenamento jurídico pátrio.

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, os réus foram abordados ao lado do local onde a droga foi encontrada, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.954/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Da mesma forma, a Sexta Turma do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. [...] 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição com fulcro no inciso VI, do art. 386, do CPP - Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Provas ilícitas - Inocorrência - Precedente STF e TJSP - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Condenação que se impõe - Causa de diminuição de pena prevista no §

4º, do art. 33, da Lei de Drogas devida no patamar mínimo - Imposição de regime inicial fechado - Recurso provido, portanto. (TJSP; Apelação 0001473-09.2016.8.26.0536; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 30/10/2018).

PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. O fato de a prisão do acusado em flagrante ter sido efetuada por guardas municipais em serviço não implica em nulidade do processo. Não demonstração de prejuízo à defesa. Inexistência de abuso ou ilegalidade na diligência realizada. Disposição do artigo 301 do Código de Processo Penal que não é afastada pela norma do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Pelo contrário, a condição de agentes públicos corrobora a idoneidade dos atos dos guardas municipais. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Acusado preso em flagrante delito tendo em depósito, em conjunto com adolescente, de 19 porções de cocaína. Guardas confirmaram a apreensão dos entorpecentes e dinheiro. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal, ausentes circunstâncias exasperantes. Inexistência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Mantida a majorante relativa ao artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, ante a comprovação do envolvimento de adolescente na traficância. Afastada a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da mesma Lei nº 11.343/06, diante da frágil comprovação quanto à natureza das atividades desenvolvidas no estabelecimento indicado na denúncia e de sua proximidade em relação ao local da traficância. Pena redimensionada para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa mínimos. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. Demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se de rigor o perdimento do valor apreendido por ocasião da prisão flagrancial, por se tratar de produto do crime, ao que se soma a ausência de demonstração da sua origem lícita. REGIME. Manutenção do regime inicial fechado. Gravidade concreta do delito diante da natureza da droga apreendida, bem como o envolvimento de adolescente na prática. BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal, anotada a insuficiência da repressão delitiva caso concedida qualquer dessas benesses. Rejeição da preliminar e, no mérito, recurso defensivo provido parcialmente para redução da pena. (TJSP; Apelação 0012875-56.2016.8.26.0320; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de Registro: 11/10/2018 - grifei).

## II - Do mérito

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

### 1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, nas fotografias de fls. 44/45, no laudo de constatação preliminar de fls. 17/19 e no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 180/182, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

### 2) Da autoria

A autoria não ficou demonstrada nos autos, no que tange ao crime previsto na denúncia.

Na fase policial, o réu Diogo afirmou que é viciado em crack há vários anos e reside nas imediações do "Bar do Pantera". Na data dos fatos, pegou alguns alimentos de sua casa para vender e comprar drogas com o dinheiro. Conhece Herik de vista e, antes de realizar as vendas dos mantimentos, parou no local para conversar, porquanto havia várias outras pessoas na localidade. Nem sabia que Herik tinha drogas consigo e somente parou no local para conversar, momento em que foi abordado pela Guarda (fls. 05/06).

Judicialmente, o réu Diogo narrou que há alguns dias, estava sem dormir. Tinha ido para sua casa, de manhã. O pedaço onde foi abordado é o local onde os usuários se encontram. Tinha alimentos da sua casa, para serem vendidos. No caminho, encontrou-se com Herik, que lhe pediu o celular emprestado, para falar com a família.

Apareceu a Guarda e tentou sair do “enquadro”. Herik lhe entregou o celular. Tinha um cachimbo no seu bolso e Herik tinha o dele. Os guardas levaram os alimentos de volta para sua tia. O local é quase uma cracolândia, as pessoas usam drogas no meio da rua. A droga foi encontrada na terra, sem sacolinha. Não tinha visto a droga com Herik e não sabia que ele tinha droga em seu poder. Usa drogas há 14 anos. Conseguia ficar sem as drogas por semanas, mas tinha recaídas. Conhecia Herik só de vista, cada um usando seu crack. Os guardas civis sabiam que eram usuários de crack. Tinha acabado de chegar ao local. Fez tratamento em Americana e esteve internado, por 03 meses, e em Piracicaba. Acha que Herik estava fazendo uso da droga ali mesmo. A porção custa de R\$ 5,00 a R\$ 10,00. Herik disse que recebeu auxílio emergencial e, por isso, tinha dinheiro para comprar a droga. O dinheiro era de Herik, mas não sabe quanto tinha. Nem sabia que Herik tinha droga, se soubesse, iria sentar ao lado dele, para usarem juntos. Uma pessoa usa quantas porções ela tiver. Se o usuário tem dinheiro, compra 10 porções (link de acesso a fls. 346).

Inquisitivamente, o réu Herik disse que é morador de rua e viciado em crack. Na data dos fatos, comprou 22 pedras de crack para consumo pessoal, na área central da cidade de Piracicaba e já havia consumido duas porções. Conhece Diogo de vista e ele foi até o local também para consumir drogas. Iria permitir que Diogo consumisse as drogas de sua propriedade, porquanto notou que ele estava “na nória” e precisava usar as substâncias (fls. 07/08).

Em Juízo, o réu Herik alegou que há 20 ou 22 dias, tinha saído da clínica, e iria para casa da irmã. No entanto, sabia que o governo estava dando o auxílio emergencial e decidiu ir buscar o benefício, e não voltar mais para casa. Conseguiu o auxílio e comprou drogas e bebidas. Usou as drogas e acabou parando perto do bar do Pantera. Consumiu uma porção. Diogo estava passando e pediu que ele emprestasse seu celular, para ligar para a irmã. Ele lhe emprestou o celular, mas não conseguiu ligar. Devolveu o celular, quando viu a viatura. Diogo saiu andando. Ele foi abordado primeiro. Levantou-se e colocou a droga que estava na sua mão na terra, atrás dele. Esse local é de uso de drogas. Também foi abordado. Dentro da sua mochila, havia um cachimbo, que o guarda jogou fora. Os guardas encontraram a droga que tinha escondido e perguntaram sobre ela. Vou levado à Delegacia. Usa drogas há 15 anos. Iria consumir a droga. Não vendia drogas. Recebeu o auxílio dois dias antes da prisão. Os guardas civis já o tinham abordado. Usou de 100 a 150 reais de drogas por dia, depois que recebeu o auxílio. No dia da abordagem, já tinha usado algumas porções de crack (link de acesso a fls. 346).

A versão dos réus não foi afastada pelos demais elementos de prova existentes nos autos. Vejamos.

O guarda municipal Claudio Jose Valverde Ocanha asseverou que estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos, um passando algo para outro. O bar estava fechado. Herik estava sentado numa muretinha e Diogo estava de pé. Resolveram abordá-los, porque o local é conhecido como ponto de tráfico e os réus são conhecidos pela prática de tráfico, inclusive já conduziu Diogo à Delegacia, com drogas, mas ele foi autuado como usuário. Já tinha abordado Herik na região do bar do Pantera. Herik tinha dinheiro. Com Diogo, nada foi encontrado. Perto de onde Herik estava a droga, na mureta. Havia 19 porções de crack. Os réus alegaram que são usuários. Não encontraram cachimbo nas imediações, nem com os réus. Geralmente, quem vai buscar droga não fica no bar ou nas proximidades. Pega a droga e vai embora consumi-la. Os réus não estavam esperando ônibus. Herik não justificou o dinheiro que estava com ele. Havia R\$ 51,00 e algumas moedas em notas trocadas. Eles demonstraram que já se conheciam. Diogo mora no bairro Morumbi e Erik disse que estava morando na rua. Viu Diogo passando algo para Herik (link de acesso a fls.346).

O também guarda municipal José Antônio de Souza Oliveira contou que estava de serviço, quando próximo do local do Pantera, verificaram dois indivíduos fazendo o tráfico: um sentado num murinho (Herik) e outro de pé (Diogo). Um entregava algo para o outro. Perto do que estava sentado, havia crack e na posse dele dinheiro. Com Diogo, nada havia. Tinham denúncias de ambos, que vendiam drogas. Os réus nada disseram sobre a droga. Já tinha abordado Diogo com droga, mas foi feito TC por

porte de drogas. Os réus não tinham petrechos para uso do crack. Estavam em deslocamento para coibir o crime. Abordaram e revistaram os réus. Não sabe dizer se o que viu um passando para o outro era droga ou não. Na aparência de Diogo, ele usa e vende, para conseguir comprar a droga. Tinham a informação e que Herik estava em situação de rua. Não se recorda de nenhuma informação de que Herik estivesse em clínica de recuperação em Piracicaba (link de acesso a fls. 346).

Milton Ferraris Sales contou que é cunhado de Herik e não presenciou os fatos narra dos na denúncia. Herik mora em Itapetininga, na sua casa. Tinham internado Herik numa clínica em Piracicaba. Depois, ele acabou fugindo, mas conseguiram encontrá-lo e levaram para outra clínica. Depois, ele reclamou com a irmã que não estava gostando e queria ir embora. Ele foi liberado da clínica, mas não voltou para casa, ficou em Piracicaba. Ele estava em Piracicaba, fora da clínica, há menos de um mês. Herik é envolvido com droga desde menino. Ele mora com ele desde os 4 anos e desde 15 ou 16 anos, passou a consumir drogas. Para conseguir dinheiro, Herik pegava objetos em casa, desfazia dos seus bens, pedia dinheiro na rua e trabalhava fazendo "bicos". Em Piracicaba, ele estava fazendo isso também. Herik dizia que estava morando na rua. Ele nunca vendeu drogas. Na clínica, o dependente só pode sair com autorização da família (link de acesso a fls. 346).

Sandra Regina de Oliveira esclareceu que é irmã de Herik. Não presenciou os fatos. Herik mora em Itapetininga. Herik foi trazido para Piracicaba, para uma clínica. Da primeira vez, ele fugiu da clínica, mas conseguiu mandá-lo de volta. Depois de um tempo, ele não queria ir mais ficar e acabou sendo liberado pela clínica. Perdeu contato com Herik. Ele virou morador de rua. Internou Herik, porque ele é dependente químico. Ele não vende drogas. Diz que Herik pedia dinheiro no semáforo e que conseguiu receber auxílio emergencial. Ele é trabalhador. Em casa, o réu vendia até a própria roupa, para comprar drogas (link de acesso a fls. 346).

A primeira questão a ser analisada é sobre a posse da droga.

Diogo, nas duas oportunidades em que foi ouvido, afirmou que só estava no local conversando com Herik e nem sabia que ele tinha droga em seu poder.

Já Herik, em solo policial, falou que havia adquirido 22 pedras de crack para seu consumo pessoal e, quando estava no bar, apareceu Diogo. Iria permitir que Diogo consumisse as drogas de sua propriedade. Em Juízo, Herik contou que recebeu auxílio emergencial dois dias antes da sua prisão e, com o dinheiro, adquiriu as drogas, para seu próprio consumo.

Os guardas municipais descreveram que já conheciam os réus, sobre quem havia denúncias de que atuavam no tráfico de drogas. No dia dos fatos, quando passaram pelo bar do Pantera, ponto conhecido como de venda de drogas, mas que estava fechado, em razão da pandemia, avistaram Diogo e Herik juntos, o primeiro entregando alguma coisa ao segundo. Herik estava sentado numa mureta e Diogo estava de pé, perto dele. Quando foram abordá-los, Diogo tentou deixar o local disfarçadamente, mas foi detido, assim como Herik. Na posse de Herik, havia dinheiro. Com nenhum deles havia drogas, no entanto, ao lado do lugar onde Herik estava sentado, encontraram 19 porções de crack. Não havia nas proximidades dos réus qualquer objeto para o uso de crack, como cachimbo.

Com efeito, temos que avaliar o envolvimento de cada um dos réus com a droga apreendida.

Os guardas civis descreveram que Diogo estava de pé e recebeu ou entregou alguma coisa a Herik, o que motivou a abordagem.

Por outro lado, embora estivessem juntos, Diogo estava de pé, ou seja, sua permanência no local não seria longa e não há comprovação de que ele tivesse em sua posse nenhum mantimento para trocar por droga.

Nesse sentido, entendo que embora haja indicação de que o réu Diogo também praticava o tráfico de drogas no local, nenhum outro elemento de prova indica que a droga apreendida lhe pertencesse. É possível que ele tivesse emprestado o celular para Herik, mas também é possível que tivesse lhe entregado dinheiro, pois Herik só tinha esse bem em seu poder.

De outro lado, nenhuma prova existe que afaste a versão de Diego de que ele não tivesse conhecimento da droga encontrada pelos guardas civis.

Concluo que não é possível a certeza sobre a imputação e, portanto, a absolvição de

Diego se impõe.

No que tange a Herik, contudo, a situação fática narrada implica em sua responsabilização pela droga encontrada pelos guardas, ao lado de onde estava sentado.

Note-se que o próprio Herik confirmou que havia adquirido a droga, para seu próprio consumo, no centro da cidade.

Nesses termos, entendo que a droga tinha relação com ele.

Ainda que assim não fosse, devemos dar crédito ao depoimento uníssono e seguro dos guardas municipais que, como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos agentes tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018 - grifei).

Toda a prova, portanto, é suficiente para saber que a droga estava sob guarda de Herik.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José

Eugênio Tedesco – RJTJRS 175/54).

“Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei” (TJRS – Ver. – Rel. Rubens Rebelo Magalhães – RJTJRS 74/11). No caso dos autos, Herik afirmou que a droga lhe pertencia, mas que era para seu próprio consumo. A prova não foi suficiente para afastar essa alegação. Vejamos. Perto do local da abordagem, há o bar do Pantera, conhecido ponto de venda de drogas da cidade que, em razão da pandemia, estava fechado. Os guardas civis já conheciam Herik e contra ele já havia denúncia de tráfico de drogas.

Os guardas civis não conseguiram indicar quem entregava e quem recebia alguma coisa para o outro e muito menos o que era entregue.

Herik, segundo as testemunhas de defesa, é morador de Itapetininga, mas estava nesta cidade para tratamento de dependência. Ele deixou a clínica, mas não retornou a sua cidade, permanecendo na rua.

Além disso, seus familiares confirmaram o envolvimento de Herik com o uso de drogas.

Nesse sentido, entendo que a prova não foi suficiente para indicar, com certeza, que Herik tinha envolvimento com o tráfico de drogas, de forma que lhe sobra a posse dos entorpecentes, sobre o qual não existe contradição.

3) Da constitucionalidade do crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06

Arguiu a Defensoria Pública que o delito de porte de entorpecentes é inconstitucional, na medida em que ofende o princípio da ofensividade.

Ocorre, no entanto, que o delito visa garantir, em primeiro plano, a saúde pública e não a saúde individual do próprio usuário. Assim, o porte da droga traz prejuízo à saúde pública, que se sobrepõe aos interesses individuais e, portanto, a conduta possui ofensividade.

De outro lado, a ausência de pena corporal traduz opção do legislador em apenas com menos rigor o usuário, mas não indica descriminalização.

É esse o entendimento da jurisprudência:

(...) POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos delitos relacionados a entorpecentes, de perigo abstrato, o que se busca é a proteção da saúde pública, não havendo que se falar na aplicação do princípio da insignificância, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida. Política legislativa. Interesse coletivo de saúde pública que se sobrepõe ao interesse individual. Ausência de penalidade com privação de liberdade e previsão de aplicação de medidas educativas que visam alertar sobre os malefícios da droga, bem como auxiliar na prevenção e recuperação do usuário ou dependente de entorpecentes. Norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política criminal vigente. (...) Importante mencionar, ainda, que não se pode acolher a alegação de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, fundada na tese de que a criminalização da conduta de posse de droga destinada ao uso pessoal violaria os princípios da ofensividade, alteridade e intimidade ou privacidade, dotados de assento constitucional, atentando contra o direito à liberdade e à individualidade do cidadão. Isso porque a criminalização da posse de droga se trata de política legislativa que visa a tutelar a saúde pública, sendo certo que o interesse coletivo se sobrepõe ao individual. Além disso, não há qualquer penalização dos usuários com privação de liberdade, mas previsão de aplicação de medidas educativas que visam alertar sobre os malefícios da droga, bem como auxiliar na prevenção e recuperação do usuário ou dependente de entorpecentes, o que atende a todos os ditames constitucionais de direito à saúde e tratamento de viciados. A esse respeito: “APELAÇÃO CRIME. ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. A criminalização das condutas descritas no art. 28 da Lei nº 11.343/06 visa a coibir a difusão da droga, resguardando a saúde pública e, sendo norma de interesse social. Assim, não afronta a garantia constitucional da liberdade individual, não havendo falar em inconstitucionalidade



do aludido dispositivo. É inadmissível que o direito à intimidade sobreponha-se ao interesse coletivo de proteção da saúde pública. 2.[...]" (TJ/RS Apelação Crime nº 70019033141, Rel. Des. José Antônio Hirt Preiss, Terceira Câmara Criminal, julgamento: 05/07/2007) "[...] Inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/06. Improcedência. Política legislativa. Ordem pública e social. Valores assegurados na Constituição Federal. Ponderação de princípios. Interpretação sistemática. Alteridade aos bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Detração anômala. Pena cumprida. Recurso da acusação desprovido e provido em parte o da defesa." (TJ/SP - APL: 0069821-29.2009.8.26.0050, Rel. Marco Nahum, 1ª Câmara de Direito Criminal, julgamento: 01/08/2011, publicação: 05/08/2011) "APELAÇÃO - Posse de drogas para uso próprio. [...] Não há falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de drogas. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública. A posse de substância entorpecente representa perigo à saúde pública, o que autoriza a penalização da conduta do agente sem que resulte ferido o seu direito à intimidade. Assim, a referida norma tutela interesse coletivo que se sobrepõe ao direito individual de liberdade, constitucionalmente assegurado. Precedentes do STF. - A Lei 11.343/06 manteve a criminalização do usuário de drogas com a finalidade de prevenir o uso indevido e de reinserir o usuário e o dependente de drogas no meio social. Não vislumbrada ofensa aos princípios constitucionais invocados. [...]" (TJ/RJ - APL: 0246021-96.2010.8.19.0001, Rel. Des. Gizelda Leitaó Teixeira, Quarta Câmara Criminal, julgamento: 08/04/2014). No mais, até o presente julgamento, a questão ainda está sendo objeto de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário 635.659, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. Dessa forma, não havendo qualquer decisão de suspensão dos efeitos de referido dispositivo e considerando que ele decorre de norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política criminal vigente, de rigor sua aplicação. (...) (TJSP; Apelação 0010003-75.2014.8.26.0405; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 20/02/2018).

#### 4) Da sanidade mental dos réus

O laudo pericial de fls. 88/95 do apenso nº 0008529-18.2020.8.26.0451, concluiu que o réu Herik não apresentava ao tempo da ação, assim como não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, DSM-V, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado incapacitante ou incompleto, doença mental, transtorno psíquico ou emocional, nem de qualquer outro distúrbio suficiente para alterar a capacidade de julgamento, nem há referências pregressas, demonstrando integridade das capacidades de discernimento, entendimento e determinação, de forma que, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Da mesma forma, o laudo pericial de fls. 96/103 do apenso nº 0008529-18.2020.8.26.0451, confirmou que Diego não apresentava ao tempo da ação, assim como não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, DSM-V, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado incapacitante ou incompleto, doença mental, transtorno psíquico ou emocional, nem de qualquer outro distúrbio suficiente para alterar a capacidade de julgamento, nem há referências pregressas, demonstrando integridade das capacidades de discernimento, entendimento e determinação, de forma que, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assim, os réus são imputáveis e como tal devem ser considerados.

#### 5) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu Herik não apresenta antecedentes criminais, mas é reincidente (certidão de fls. 59 - Processo nº 0000406-64.2017.8.26.0269), de forma que sua pena deve ser de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses.

Pena final para o réu Herik: prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para 1) ABSOLVER DIOGO OLIVEIRA MAIELLI, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 29 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 2) DESCLASSIFICAR o delito imputado e CONDENAR HERIK AUGUSTO FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses. Nos termos do artigo 28, parágrafo 5º, da Lei nº 11.343/06, "a prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas".

O dinheiro apreendido em poder de Herik pode-lhe ser devolvido, já que não comprovado o tráfico de drogas.

Concedo aos réus a gratuidade processual.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piracicaba, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA